

1512545-39.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... réu tivesse concorrido para o crime de tráfico. Invoca o 'in dubio pro reo'. O acusado seria usuário de drogas. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Cita doutrina e jurisprudência. Em caso de condenação, requer o reconhecimento de tráfico privilegiado, pena mínima. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512545-39.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512545-39.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2225319/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 19712002 - 02º D.P. AMERICANA, 1252/21/345 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILCKER ROBSON PAULINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

WILCKER ROBSON PAULINO DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 18 de agosto de 2021, por volta de 20h46, na Rua das Azaléias, 806, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, ocultada na calça e na cueca, sacola plástica, dois recipientes: um, com dezessete invólucros plásticos fechados da substância cocaína, apurada massa de 5,1 gramas; outro, com treze invólucros plásticos de cocaína, pesando 8,5 gramas, embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, além de R\$ 198,00, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 09/11/2021 (fls. 132/133) e o réu citado (fls. 158). Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime, alertando, em complementação, ser o réu reincidente (fls. 172/175).

A Defesa pugnou pela absolvição por inexistência de provas ou de que o réu tivesse concorrido para o crime de tráfico. Invoca o 'in dubio pro reo'. O acusado seria usuário de drogas. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Cita doutrina e jurisprudência. Em caso de condenação, requer o reconhecimento de tráfico privilegiado, pena mínima. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 179/185).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

O réu foi preso em flagrante e preservou em silêncio, atitude que embora resguardada constitucionalmente, normalmente não se compatibiliza com a de quem brada inocência.

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, Do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

Em Juízo, o réu negou a prática do delito. Alegou ser usuário de drogas. Estava em um bar, tomando uma cerveja, encostado em um carro. O veículo estava parado. Tinha acabado de comprar um pino de pó. A droga estava aberta, em sua cintura. Portava a quantia de R\$ 198,00 em seu bolso. Foi abordado e os guardas localizaram o entorpecente. Havia um rapaz, um pouco mais para baixo de onde estava, que se evadiu. Uma viatura tentou interceptá-lo, mas não o localizaram. O GCM Siderlei disse que pelo fato de ter verificado que possuía passagens criminais seria conduzido até a Delegacia. Trabalhava com reciclagem e iria trabalhar como ajudante de servente com o seu cunhado, ele iria registrá-lo. Os dois Kits de drogas não eram seus, apenas o pino e o dinheiro, provenientes da reciclagem que vendeu.

A negativa do réu não convence.

Siderlei Aparecido de Almeida, guarda municipal, esclareceu que efetuava patrulhamento preventivo para tentativa de combate ao tráfico na região, quando entraram na Rua Azaléias. Tinha um Bar na esquina e viram quando Wilcker encostou no veículo Corolla. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Durante a revista pessoal, localizaram em seu poder dois kits de drogas, uma delas misturada (mais barata) e outra nine-nine (um pouco mais cara), além da quantia de R\$ 190,00.

O GCM Wilson percebeu que o condutor do veículo, antes de deixar o local, jogou duas porções de drogas no chão, cujo entorpecente era semelhante aos encontrados com Wilcker. Indagado, o acusado confessou a traficância e foi conduzido até a Centra de Polícia Judiciária.

Wilson Júnior Rodrigues, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que a equipe patrulhava pela Rua dos Lilases, entraram na via e avistaram o acusado encostado em um veículo Corolla. Quando se aproximaram para realização da abordagem, o condutor do veículo notou a presença da viatura e dispensou duas porções de drogas no chão, enquanto Wilcker tentou sair pela Rua das Azaléias. Ele foi abordado e revistado. Com o réu, localizaram dinheiro e porções de drogas. Conduziram-no até o plantão policial. Não ouviu qualquer versão do acusado, que foi abordado pelo GCM Siderlei, enquanto tentava deter o condutor do veículo Corolla, mas não teve êxito.

A prova desfavorece ao réu, como se vê.

Ele foi visto em local notório de venda de drogas, mantendo contato com outro homem, em um veículo Corolla. O condutor, suspeitosamente, evadiu-se com o carro, não sem antes arremessar dois embrulhos no chão (duas porções de cocaína). O réu até tentou fuga, mas foi detido e revistado, quando então localizaram, na sua cintura, sacola plástica com expressiva quantidade de drogas (para a circunstância) -13 porções de cocaína (plástico amarelo, que dizem ter maior pureza) e 17 porções de cocaína (acondicionadas no plástico branco, de menor pureza), além da quantia de R\$ 198,00 em suas mãos.

O réu, mesmo tendo sido visto pelos dois guardas civis com as drogas e o valor, quis negar, alegando que apenas o pino de cocaína e o dinheiro lhe pertenceriam, mas não convence.

Não fez comprovação alguma de sua negativa, não se olvidando que o local era conhecido pela venda de entorpecentes, o que se reafirma pelo fato de o réu manter contato com provável adquirente da droga, em veículo que se evadiu e cujo condutor dispensou, também, duas porções de drogas semelhantes às que o réu levava.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

O réu não fez comprovação alguma da sua negativa.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um alibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

Não beneficia ao réu o fato de não ter sido pilhado vendendo droga, quando a denúncia é certa em o acusar de trazer com ele as drogas, para esse fim.

É que se trata de crime de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Na doutrina:

"Nota-se facilmente que o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, isto é, possui várias condutas típicas separadas pela conjunção alternativa "ou". Em razão disso, a pluralidade de condutas envolvendo o mesmo objeto material constitui crime único. Exemplo: adquirir, transportar, guardar e depois vender a mesma substância entorpecente. Nesse caso, há um só crime, porque as diversas condutas são fases sucessivas de um mesmo ilícito. Os crimes de ação múltipla são também chamados de crimes de conteúdo variado ou de tipo misto alternativo. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, é suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo desnecessária a realização de atos de venda do entorpecente." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, 2020, pág.87, Legislação Penal esquematizada).

E na jurisprudência:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes

do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente:

"ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Não se pode desprestigiar o depoimento de guarda municipal, que bem se lembrou dos fatos e imputou ao réu a autoria, de tráfico.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846);

O réu, também, não era noviço na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo laudo de constatação (fls. 09/11), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 76/78).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu possui Maus antecedentes (vg. Processo nº 0006332-38.2014.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/12/2015). A pena deverá ser fixada acima do mínimo legal pelos Maus antecedentes do acusado.

Fixo a pena base, pois, com essas considerações, em seis (06) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que os demais antecedentes contra o réu são antigos (vg. Processo nº 0020050-78.2009.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/07/2011 e Processo nº 0003798-40.2008.8.26.0114 - 5ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/09/2009). A condenação no Processo nº 0006449-73.2017.8.26.0229 pelo artigo 28, "caput" do SISNAD é igualmente inábil para a reincidência, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividades criminosas e nem integrassem organização criminosa, primário, reduzo a pena em 1/3 (um terço), assim a tornando definitiva (4 anos e 400 dias-multa).

É de se impor o regime inicial semiaberto, pela somatória da pena, reclusiva, não se mostrando socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aqui por que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, na fixação da pena, em especial a nocividade da droga traficada.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

"...Todavia, evidenciadas as peculiaridades do caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a culpabilidade exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf. artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida em que atende agente que cometeu grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a referida substituição." Apelação Criminal nº 1500108-35.2019.8.26.0536, sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 14 de outubro de 2020. RICARDO SALE JÚNIOR Relato

No C. STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie (como o imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada), em decorrência da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS E no E. TJSP:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso ministerial. Pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e quantidade de drogas que não se mostra excessiva. Inexistência de prova nos autos de que o apelado se dedique a atividades criminosas ou de que pertença a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda que não comporta reparos. Negado provimento ao recurso" (TJSP Apelação nº 1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de

São Paulo, julgado em 09 de março de 2020).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra WILCKER ROBSON PAULINO DA SILVA condenando-o às penas de quatro (04) anos de reclusão, regime inicial semiaberto e quatrocentos (400) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006. Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 120).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Faculto ao réu recurso em liberdade, mercê da pena imposta, já tendo cumprido lapso temporal razoável para eventual progressão (requisito objetivo), o que deverá ser manejado em execução de pena, provisória ou definitiva.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Americana, 31 de janeiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA